

Dispense di Impianti sportivi
norme di prevenzione e gestione

A.A. 2025/2026

Indice

1	La definizione di impianto sportivo e il servizio pubblico	1
1.1	La Carta Europea dello Sport (1992)	1
1.1.1	Accesso e promozione della pratica sportiva	1
1.1.2	La pianificazione degli impianti	1
1.1.3	La definizione di sport	2
1.2	La definizione di sport nell'ordinamento italiano	2
1.2.1	Il riconoscimento delle discipline sportive: delibera C.N. CONI 1568/2017	2
1.3	Le fonti legislative nazionali	3
1.3.1	L'art. 117 Cost. e la competenza concorrente	3
1.3.2	Il D.P.R. 616/1977 sul decentramento regionale	4
1.3.3	Lo Statuto del CONI	4
1.4	L'impianto sportivo	4
1.4.1	La definizione	4
1.4.2	Il sistema degli impianti sportivi	4
1.4.3	La natura giuridica del bene	5
1.5	La gestione dell'impianto come servizio pubblico	5
1.5.1	La nozione di servizio pubblico	5
1.5.2	La gestione dell'impianto sportivo	5
1.5.3	La valenza pubblicistica nello Statuto CONI	6
1.5.4	L'apertura dell'impianto a tutti i cittadini	6
2	La concessione e l'appalto di servizi pubblici	7
2.1	Concessione o appalto di servizi?	7
2.1.1	Il costo del servizio	7
2.1.2	Il rischio di gestione	7
2.1.3	Il rapporto diretto con l'utenza	7
2.1.4	I caratteri distintivi	8
2.1.5	La definizione del codice dei contratti pubblici	8
2.2	La natura di servizio pubblico nella giurisprudenza	8
2.3	La disciplina applicabile all'affidamento	9
2.3.1	Il quadro previgente: l'art. 30 D.Lgs. 163/2006	9
2.3.2	La norma quadro: art. 90 legge 289/2002, comma 25	9
2.3.3	Gli orientamenti giurisprudenziali	10
3	La possibile rilevanza economica degli impianti	12

3.1	Il nuovo codice dei contratti pubblici	12
3.2	La classificazione dei servizi pubblici	12
3.3	I criteri della rilevanza economica	13
3.3.1	Il punto di partenza e la sua smentita	13
3.3.2	I due criteri	13
3.3.3	La valutazione caso per caso	13
3.3.4	Ciò che non rileva: la natura dell'affidatario	14
3.3.5	Le variabili del settore sportivo	14
3.3.6	La sintesi	14
3.4	La disciplina degli impianti privi di rilevanza economica	15
3.4.1	Prima ipotesi: la delibera ANAC 1300/2016	15
3.4.2	Seconda ipotesi: gli artt. 4 e 30 del codice	16
4	Le leggi regionali in materia di impiantistica sportiva	17
4.1	Il rinvio alla legge regionale	17
4.2	La Valle d'Aosta: L.R. 18/2006, art. 10	17
4.3	L'affidamento diretto alle Federazioni sportive nazionali	18
4.4	Dalla Puglia all'Emilia-Romagna	19
4.4.1	Puglia — L.R. 33/2006, art. 18 (mod. L.R. 32/2012)	19
4.4.2	Lombardia — L.R. 27/2006	20
4.4.3	Umbria — L.R. 5/2007, art. 4	20
4.4.4	Liguria — L.R. 40/2009, art. 19	20
4.4.5	Sardegna — L.R. 17/1999, art. 21	21
4.4.6	Molise — L.R. 18/2011, art. 2	21
4.4.7	Marche — L.R. 5/2012, art. 19	22
4.4.8	Campania — L.R. 18/2013, art. 20	22
4.4.9	Toscana — L.R. 21/2015, art. 14	23
4.4.10	Veneto — L.R. 8/2015, artt. 25–26	23
4.4.11	Emilia-Romagna — L.R. 8/2017	23
4.5	La competenza all'affidamento: Giunta o Consiglio comunale?	24
4.6	Sintesi della disciplina applicabile	24
5	Le forme di partenariato pubblico privato	25
5.1	La nozione di partenariato pubblico privato	25
5.2	L'allocazione dei rischi	25
5.3	L'equilibrio economico-finanziario e il prezzo	26

5.4	La contabilizzazione off balance e il ricorso al mutuo	27
5.5	Le questioni interpretative sul limite del 49%	27
5.6	I fondi immobiliari	29
5.7	Le tipologie di contratti di PPP	29
5.8	Le procedure di affidamento	29

1 La definizione di impianto sportivo e il servizio pubblico

Il corso muove dalle definizioni e dai concetti di base — che cosa sia “sport”, che cosa sia “impianto sportivo”, quali norme se ne occupino — per arrivare al punto che regge tutta la materia: la gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica è un **servizio pubblico**, e resta tale qualunque sia la sua rilevanza economica e qualunque forma di affidamento venga scelta.

1.1 La Carta Europea dello Sport (1992)

Carta Europea dello Sport (1992): atto del legislatore comunitario che affronta il tema degli impianti in modo ampio, declinando l’attività sportiva non necessariamente in senso agonistico. Le sue affermazioni sono in buona parte **di principio**, ma è la sostanza che vi sta dietro a orientare la disciplina nazionale degli impianti.

1.1.1 Accesso e promozione della pratica sportiva

- **accesso non discriminatorio**: l’accesso agli impianti o alle attività sportive è garantito senza distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status;
- **possibilità effettiva di praticare**: provvedimenti perché tutti i cittadini possano praticare lo sport, con misure supplementari — ove necessario — per i **giovani più dotati**, i **disabili** e i **gruppi svantaggiati**;
- **accesso facilitato**: i proprietari di impianti adottano le misure necessarie per facilitare l’accesso dei gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisico o mentale;
- **promozione in tutte le fasce di popolazione**: sia come divertimento, sia per ragioni di salute, sia per migliorare le prestazioni, offrendo impianti adeguati, programmi diversificati e istruttori, dirigenti o “animatori” qualificati;
- **sport sul luogo di lavoro**: la partecipazione ad attività sportive sul luogo di lavoro va incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata.

Se l’uso degli impianti pubblici deve essere garantito all’intera collettività, il ragionamento va condotto in termini di **servizio pubblico**: la vocazione collettiva dell’impianto pubblico è la stessa di una scuola, di un ospedale, di un teatro. La rilevanza economica della gestione non si sottovaluta, ma la sfera e il controllo pubblicistico restano sempre in rilievo.

1.1.2 La pianificazione degli impianti

Pianificazione globale degli impianti: è **competenza dei poteri pubblici**, perché la pratica sportiva dipende in parte dal numero, dalla varietà e dall’accessibilità degli impianti.

- **riferimenti della pianificazione**: esigenze nazionali, regionali e locali, e impianti pubblici, privati e commerciali **già esistenti**;
- **obblighi dei responsabili**: provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, **in tutta sicurezza** (il tema della sicurezza è declinato dal D.M. 18 marzo 1996 e non solo);

- **criticità italiana:** programmazione urbanistica e impiantistica datata e scarso dialogo fra amministrazioni diverse → impianti dello stesso tipo vicini fra loro → reciproca erosione della rilevanza economica e della **sostenibilità economico-finanziaria**;
- **varietà dell'offerta:** la programmazione va ragionata in termini di offerta sportiva complessiva, non del singolo impianto.

1.1.3 La definizione di sport

Sport (Carta Europea dello Sport): “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

- è una definizione **più ampia** di quella corrente, che identifica lo sport con l'attività fisica finalizzata a una competizione — cioè misurabile, con una classifica, e riconducibile a un comitato olimpico;
- ai fini della **programmazione pubblicistica** rileva invece anche l'attività organizzata *o non*, e anche il solo miglioramento della condizione fisica o psichica.

1.2 La definizione di sport nell'ordinamento italiano

Assenza di una definizione legislativa: nella legislazione domestica non esiste una definizione di sport. Quando la normativa italiana si riferisce allo sport, all'ordinamento sportivo o alle politiche sportive, lo fa senza aver stabilito a priori che cosa debba intendersi per sport.

- **definizione del dizionario Garzanti:** “l'insieme degli esercizi fisici che si praticano, in gruppo o individualmente, per mantenere in efficienza il corpo”;
- **limite della definizione:** fra le discipline sportive associate riconosciute dal CONI ci sono **bridge**, **dama** e **scacchi**, che non prevedono movimenti tesi a conservare la funzionalità del corpo → sport non equivale necessariamente a movimento, e il concetto di attività sportiva si estende alla **ginnastica della mente**.

1.2.1 Il riconoscimento delle discipline sportive: delibera C.N. CONI 1568/2017

Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1568/2017 (e successive modifiche): per la prima volta in termini espliciti il CONI effettua una **ricognizione** delle discipline sportive riconosciute, con elenco allegato. Ha come unico precedente una delibera del dicembre 2016.

Perché nasce

- le **associazioni e società sportive dilettantistiche** godono di **agevolazioni fiscali**, concesse a chi è riconosciuto dal CONI e iscritto al **Registro nazionale** delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- il CONI, quale **ente certificatore** dell'attività sportiva dilettantistica, ha istituito il Registro come strumento amministrativo;
- su sollecitazione dell'**amministrazione finanziaria** e dell'**ispettorato del lavoro** ha poi dovuto individuare le discipline per le quali le affiliate a enti e federazioni possono ottenere il riconoscimento;
- **effetto:** l'iscrizione al Registro, che vale come riconoscimento ai fini sportivi del CONI, si consegue **esclusivamente** per le discipline dell'elenco allegato.

Criterio utilizzato

I tre principi ispiratori della lista originale sono le discipline sportive:

1. riconosciute dal **CIO**;
2. riconosciute da **Sportaccord**;
3. presenti negli **statuti delle FSN** (federazioni sportive nazionali) e **delle DSA** (discipline sportive associate) approvati dalla Giunta Nazionale CONI.

La delibera dà però atto di aver accolto parte delle richieste avanzate da FSN, DSA ed **EPS** (enti di promozione sportiva) “nonostante alcune integrazioni non risultino conformi” a quei tre principi.

Esito

385 discipline sportive riconosciute. Il riconoscimento di alcune discipline a fronte di altre ha generato contestazioni; fra le più note **non** comprese:

- **non riconosciute:** yoga, feldenkrais, shiatsu e tutte le attività “olistiche”; crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre; alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” (attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua); poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge; MMA, krav maga, paintball e simili;
- **riconosciute da CIO e CONI ma senza FSN o DSA:** flying disc (frisbee);
- **riconosciute dalla Federazione Internazionale di ginnastica ma non dal CONI:** sprint ostacoli e freestyle ostacoli (parkour).

1.3 Le fonti legislative nazionali

Le principali — in realtà le uniche — fonti normative nazionali in materia di sport:

- **art. 117 Costituzione:** competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo;
- **Legge 16 febbraio 1942 n. 426:** istitutiva del CONI (abrogata);
- **D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242** (*decreto Melandri*), modificato dal **D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15** (*decreto Pescante*): riordino del CONI;
- **Legge 23 marzo 1981 n. 91:** norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;
- **art. 90 legge 289/2002** (finanziaria per il 2003): disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.

1.3.1 L’art. 117 Cost. e la competenza concorrente

Art. 117 Cost.: l’ordinamento sportivo è materia di **legislazione concorrente**; nelle materie concorrenti la potestà legislativa spetta alle Regioni, salva la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato.

- **ingresso in Costituzione:** 2001, con la riforma costituzionale del decentramento regionale, salutato inizialmente con favore;
- **meccanismo della competenza concorrente:** lo Stato definisce una normativa quadro; dentro la cornice così tracciata, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano normano in modo più specifico, anche in base alle connotazioni territoriali;
- **scelta lessicale del costituente:** non “sport” ma “**ordinamento sportivo**”, cioè un ordinamento **separato e autonomo**, non sovrano — la sua sovranità cede di fronte alla supremazia dell’ordinamento statale;

- **difficoltà applicativa:** “ordinamento sportivo” è la stessa espressione con cui il legislatore nazionale designa l'ordinamento che fa capo al **CONI**, ente pubblico posto al suo vertice (decreti Melandri e Pescante).

PROBLEMA: non esiste una legge quadro sullo sport. Quasi tutte le Regioni hanno adottato dopo il 2001 — alcune con più ritocchi, qualcuna ferma a prima della riforma — una **legge regionale in materia di sport**, pur in assenza della legge quadro statale in materia di ordinamento sportivo.

1.3.2 Il D.P.R. 616/1977 sul decentramento regionale

Art. 56 D.P.R. 616/1977: attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la **promozione di attività sportive e ricreative** e la **realizzazione dei relativi impianti e attrezzature**.

- **intesa con gli organi scolastici:** per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare;
- **riserva al CONI:** restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle **attività agonistiche a ogni livello** e le relative **attività promozionali**;
- **consulenza tecnica:** per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Zona grigia: se la competenza del CONI sull'organizzazione dell'attività agonistica è chiara, è molto meno netto il confine fra le **attività promozionali connesse all'agonismo** (CONI) e la **promozione di attività sportive e ricreative** (Regioni).

1.3.3 Lo Statuto del CONI

Statuto CONI, art. 2 comma 3: il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, sia per i normodotati sia — di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico — per i disabili, **ferme le competenze delle Regioni** e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

- il CONI è **ente pubblico** e il suo statuto è approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **rinvio circolare:** la norma statale fa salve le attribuzioni del CONI, lo statuto CONI fa salve le competenze delle Regioni — competenze che però non sono mai state espressamente definite.

1.4 L'impianto sportivo

1.4.1 La definizione

Impianto sportivo (D.M. Ministero dell'Interno 18 marzo 1996): “insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive”.

1.4.2 Il sistema degli impianti sportivi

La definizione appare ovvia per lo stadio o il palazzetto, ma la nozione ampia di sport porta a comprendere anche spazi privi di vocazione sportiva esclusiva. Il sistema comprende:

- gli **stadi** e i grandi impianti per lo spettacolo sportivo;
- gli **impianti per le attività agonistiche** a tutti i livelli, sia pubblici sia privati;
- le **palestre** e le **piscine**;
- gli **impianti scolastici**;
- i **parchi urbani**, le piste ciclabili, i percorsi vita;
- lo “**sport senza impianti**”: fiumi, specchi d'acqua, ambiente — definizione volutamente provocatoria, riferita agli sport praticabili in spazi senza vocazione sportiva esclusiva.

Gestore: responsabile della vita dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.

1.4.3 La natura giuridica del bene

Consiglio di Stato n. 2385/2013: l'impianto sportivo rientra nell'ultimo capoverso dell'**art. 826 c.c.**, cioè fra i beni di proprietà dei Comuni **destinati a un pubblico servizio**.

- **regime giuridico:** beni **patrimoniali indisponibili**, che ex **art. 828 c.c.** non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- **vincolo funzionale:** coerente con la vocazione naturale del bene a essere impiegato in favore della collettività, per attività di interesse generale — e la conduzione degli impianti sportivi rientra in tale tipologia di attività;
- **proprietà:** nella grande maggioranza dei casi comunale; esistono impianti di proprietà di province (ed ex province) o regioni.

1.5 La gestione dell'impianto come servizio pubblico

1.5.1 La nozione di servizio pubblico

Servizio pubblico:

- **profilo dell'attività:** un complesso di operazioni funzionalmente coordinate, il cui prodotto è rappresentato da **utilità** poste a disposizione degli utenti per il soddisfacimento di **bisogni eterogenei**;
- **profilo sostanziale:** attività **economica** che mira a soddisfare bisogni così largamente avvertiti da essere considerati propri di una collettività → riconoscimento di una **funzione sociale**.

1.5.2 La gestione dell'impianto sportivo

Gestione di un impianto sportivo: insieme di attività volte ad assicurare il **funzionamento** dell'impianto e l'**erogazione del servizio sportivo** che vi si svolge.

- rientra a pieno titolo nell'area dei **servizi pubblici**;
- più in particolare nell'ambito dei **servizi alla persona** o **servizi sociali** — collocazione che si ritrova poi nei singoli regolamenti comunali.

Conferme giurisprudenziali

- **profilo oggettivo:** “per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come

nel caso della gestione di impianti sportivi comunali” (C.d.S. sez. IV n. 6325/2000; C.d.S. sez. VI n. 1514/2001; TAR Lombardia Milano sez. III n. 5633/2005);

- **destinazione naturale del bene:** un centro sportivo strutturato in una piscina di proprietà comunale “è un bene che per sua natura è destinata ad essere adibita ad un uso pubblico”, e l’attività inerente ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come servizio pubblico (C.d.S. sez. V n. 4265/2008).

1.5.3 La valenza pubblicistica nello Statuto CONI

Statuto CONI, art. 23 comma 1: hanno **valenza pubblicistica** le attività delle Federazioni sportive nazionali relative, fra l’altro, all’**utilizzo e alla gestione degli impianti sportivi pubblici**.

- le FSN hanno natura giuridica di **associazioni riconosciute di diritto privato**;
- per una serie di materie delegate dal CONI esercitano però **poteri pubblicistici**, e fra queste rientra la gestione degli impianti pubblici.

1.5.4 L’apertura dell’impianto a tutti i cittadini

Art. 90 legge 289/2002, comma 24: l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è **aperto a tutti i cittadini** e deve essere garantito, sulla base di **criteri obiettivi**, a tutte le società e associazioni sportive.

- è la **norma quadro** che riprende il principio di partenza della Carta Europea dello Sport, pur essendo contenuta in una disposizione dedicata all’attività dilettantistica;
- vale **indipendentemente** dalle modalità di affidamento e di gestione dell’impianto pubblico: il bene, quale patrimonio indisponibile gravato da vincolo funzionale, non può essere sottratto alla propria vocazione.

2 La concessione e l'appalto di servizi pubblici

Quando l'ente pubblico affida a un soggetto privato — nel caso tipico una società sportiva — la gestione di un impianto, occorre stabilire se l'affidamento sia una **concessione** o un **appalto di servizi**. La distinzione non è nominalistica: da essa dipendono le modalità concrete di affidamento, che sono diverse nei due casi.

2.1 Concessione o appalto di servizi?

2.1.1 Il costo del servizio

Criterio del costo: su chi grava il corrispettivo dell'attività.

- **concessione di pubblici servizi:** il costo del servizio grava sugli **utenti** → presuppone sia che il servizio sia reso a **terzi** (e non all'Amministrazione), sia che il corrispettivo sia **in tutto o in parte** a carico degli utenti;
- **appalto di servizi:** spetta all'**Amministrazione** l'onere di compensare l'attività svolta dal privato → la prestazione è resa in favore dell'**ente aggiudicatore** e a **titolo oneroso**.

Perché “in tutto o in parte”

L'Amministrazione può erogare al gestore un **contributo di gestione**: il privato non fissa liberamente le tariffe all'utenza, ma deve applicare le **tariffe calmierate** approvate dall'Amministrazione e previste in convenzione. Se il Comune, fedele alla vocazione pubblicistica del servizio, impone tariffe inferiori a quelle di mercato, il contributo serve a garantire l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione.

Il caso opposto

Se l'Amministrazione gestisce direttamente l'impianto e appalta i singoli servizi scorporati (pulizie, ristorazione, punto vendita), quei servizi sono compensati direttamente da essa e il privato non ha alcun rapporto con l'utenza: ricorre l'**appalto**.

2.1.2 Il rischio di gestione

Rischio di gestione: è l'elemento caratterizzante la concessione rispetto all'appalto.

- la **concessione** si configura ogni qual volta l'aggiudicatario assuma il rischio della gestione economica del servizio prestato, della sua istituzione e gestione;
- il concessionario sostiene una **parte considerevole** dell'alea economica — la parte sostanziale, non necessariamente la totalità, visto l'eventuale contributo pubblico — che altrimenti farebbe capo all'Amministrazione;
- nell'**appalto** il rischio di gestione resta in capo alla Pubblica Amministrazione.

2.1.3 Il rapporto diretto con l'utenza

Dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche: ricorre la **concessione di pubblico servizio**, e non l'appalto, quando a un soggetto esterno alla PA è affidata la fornitura di un servizio rivolto al **pubblico degli utenti**, con i quali l'affidatario costituisce **direttamente rapporti di tipo giuridico** (Cons. Stato sez. V n. 2294/2002; TAR Emilia Romagna sez. Parma 18.09.1995 n. 317; TAR Lombardia sez. Milano 4.08.2004 n. 3242).

2.1.4 I caratteri distintivi

	Concessione	Appalto
Natura del titolo	unilaterale, con effetto accrescitivo dei poteri del privato	negoziale: il privato esercita i poteri propri dei privati
Destinatario diretto	utenza pubblica	Pubblica Amministrazione
Rischio di gestione	in capo al privato	in capo alla PA
Rapporto	trilaterale	contratto a prestazioni corrispettive
Costo del servizio	ricade sull'utenza	se lo assume la PA

Tabella 2.1: Concessione e appalto di servizi: caratteri distintivi.

- **effetto accrescitivo dei poteri:** nella concessione l'Amministrazione concede al privato di erogare in sua sostituzione un servizio pubblico → il privato affianca ai poteri propri dell'operatore economico anche poteri di natura pubblicistica;
- **appalto:** contratto tipico del codice civile, sinallagmatico, a prestazioni corrispettive;
- **rapporto trilaterale** della concessione: Amministrazione proprietaria → privato gestore che si sostituisce a essa nell'erogazione → utenza, che si fa carico in tutto o in parte del costo del servizio.

2.1.5 La definizione del codice dei contratti pubblici

Concessione di servizi (art. 3 D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici): “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ... riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo** legato alla gestione dei servizi”.

- il “prezzo” che può accompagnare il diritto di gestione è il **contributo pubblico**;
- **conclusione:** nella gestione di un impianto sportivo ricorre **generalmente la concessione di servizi**, perché a fronte dell'affidamento il corrispettivo consiste anche o solo nella gestione dello stesso, e l'alea è in capo al gestore e non alla PA — l'incognita è la risposta dell'utenza all'offerta sportiva, date le tariffe stabilite dall'Amministrazione, e quindi il ritorno economico della gestione.

2.2 La natura di servizio pubblico nella giurisprudenza

TAR Lombardia sez. III n. 5021/2009: i tratti distintivi del servizio pubblico sono ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale.

- è attività **oggettivamente correlata** alla realizzazione di interessi pubblici, perché funzionale per caratteristiche intrinseche a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva;
- l'attività sportiva è **strettamente connessa con la tutela della salute**, che l'**art. 32 Cost.** individua quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività → la natura pubblicistica della gestione si ancora anche a questo diritto fondamentale, oltre che al carattere sociale del servizio;
- è attività prestata **direttamente in favore degli utenti** per soddisfare interessi di rilevanza generale.

Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia n. 124/2011: quel principio di fondo deve trovare concreta attuazione nell'osservanza, da parte del gestore, di **livelli minimi di servizio** per quantità e qualità, nonché nella **continuità e regolarità** del servizio in favore della collettività degli utenti. La verifica fattuale va compiutamente assolta dall'ente locale, per configurare correttamente l'affidamento in termini di concessione di pubblico servizio.

- **livelli quantitativi:** giorni e orari di apertura da fissare nell'atto concessorio;
- **livelli qualitativi:** figure qualificate richieste (direttori di impianto, istruttori specializzati), coerentemente con la normativa regionale di riferimento;
- **continuità:** un servizio pubblico non può essere interrotto → l'Amministrazione non può limitarsi a concedere il bene, ma deve imporre e verificare questi standard.

2.3 La disciplina applicabile all'affidamento

2.3.1 Il quadro previgente: l'art. 30 D.Lgs. 163/2006

Art. 30 comma 1 D.Lgs. 163/2006 (abrogato dal D.Lgs. 50/2016): “salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”.

- per questa esclusione espressa il D.Lgs. 163/2006 era di fatto un **codice degli appalti** e non un vero codice dei contratti pubblici;
- per l'affidamento in concessione di servizi pubblici come quello sportivo si riteneva quindi legittimamente prevalente la **normativa regionale**;
- in mancanza di questa valevano le indicazioni generali della seconda parte dell'art. 30 stesso.

Principi della seconda parte dell'art. 30

La scelta del concessionario doveva avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali sui contratti pubblici, in particolare:

- trasparenza;
- adeguata pubblicità;
- non discriminazione;
- parità di trattamento;
- mutuo riconoscimento;
- proporzionalità;
- previa gara informale.

Alla gara informale sono invitati **almeno cinque concorrenti**, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con **predeterminazione dei criteri selettivi**.

2.3.2 La norma quadro: art. 90 legge 289/2002, comma 25

Art. 90 comma 25 L. 289/2002: “nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di **convenzioni** che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le **Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento**”.

- a differenza dell'ordinamento sportivo, privo di legge quadro, in materia di impianti sportivi esiste dunque una **vera norma quadro**, ed è quella che ha consentito finora alle Regioni di legiferare;

- il criterio di **preferenzialità** è di difficile decodificazione — le Regioni che hanno provato a declinarlo lo hanno fatto con fatica — ed è stato attenzionato dall'**Unione Europea** come norma che violerebbe la concorrenza e la *par condicio* fra operatori economici.

Sul piano operativo la preferenzialità non è mai **affidamento diretto**: resta ferma in ogni caso la necessità di una **pubblicità preventiva**. Le Regioni che le hanno dato il contenuto più esplicito — Molise, Toscana e Veneto — la traducono in una **priorità procedurale**: una prima procedura riservata ai soggetti sportivi, e l'apertura ad altri soggetti solo in caso di **esito infruttuoso**; soluzione a sua volta già censurata dalla Commissione europea per violazione dei principi sulla concorrenza (cap. 4).

2.3.3 Gli orientamenti giurisprudenziali

Obbligo di evidenza pubblica

Cons. Stato sez. V 29 dicembre 2009 n. 8914 (su L.R. Lombardia 27/2006 art. 2): afferma sia la **necessità di una procedura ad evidenza pubblica** per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, sia la possibilità per gli interessati di chiedere l'inserimento nel bando di **requisiti di selezione ulteriori**, logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, fermi i limiti di logicità, ragionevolezza, pertinenza e congruità rispetto allo scopo perseguito.

Affidamento diretto e impianto privo di rilevanza economica

Cons. Stato sez. V 27 settembre 2011 n. 5379 (su L.R. Lombardia 27/2006 art. 5): stante l'esatta qualificazione dell'impianto come **privo di rilevanza economica**, il Comune ha correttamente proceduto ad **affidamento diretto** ex art. 5 comma 2 della legge regionale, avendo comunque rispettato i principi di **trasparenza e imparzialità** imposti dalla disciplina comunitaria.

- **il caso**: una società sportiva non affidataria impugna l'affidamento diretto disposto dal Comune, prima davanti al TAR Lombardia e poi in appello;
- **i due elementi decisivi**: la natura di impianto privo di rilevanza economica, e il fatto che l'affidataria fosse una **polisportiva comunale** aperta a tutte le associazioni sportive del territorio, espressamente invitate, che ben potevano e possono aderirvi in qualunque momento → pur essendo l'atto finale un affidamento diretto, a monte si era cercato di riunire in un unico soggetto tutti gli operatori interessati.

La disciplina lombarda su cui le due pronunce si fondano (cap. 4): la L.R. 27/2006 è la legge regionale che più di ogni altra **differenzia la procedura di selezione** a seconda che l'impianto abbia o meno rilevanza economica. Per gli impianti **con** rilevanza economica che per dimensioni e altre caratteristiche richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, le società e associazioni sportive diletteristiche devono dimostrare di possedere i **requisiti imprenditoriali e tecnici** necessari; per quelli **senza** rilevanza economica è ammesso l'**affidamento diretto**, anche agli **utilizzatori** degli impianti stessi.

Rinnovo e proroga della concessione

Cons. Stato sez. V n. 6132/2011:

- il **rinnovo** di una concessione può essere legittimamente disposto bandendo una gara, essendo le PA sempre assoggettate all'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per individuare il contraente;
- il **precedente concessionario** va posto sullo stesso piano di ogni altro soggetto richiedente — non vanta alcun diritto di insistenza o di prelazione — e la gara può essere indetta senza particolare motivazione sul

diniego del rinnovo;

- lo **stesso principio** vale quando il gestore si offra di accollarsi la realizzazione di **interventi strutturali** (copertura o realizzazione della tribuna, rifacimento degli spogliatoi) chiedendo in cambio una **proroga**: l'operazione non è ammissibile se la possibilità di proroga non era esplicitamente prevista nella procedura di affidamento originaria, così che ogni altro operatore economico potesse conoscere fin dal bando la durata potenzialmente più lunga dell'affidamento.

3 La possibile rilevanza economica degli impianti

Stabilito che la gestione di un impianto sportivo è di regola una concessione di servizi, il nuovo codice dei contratti pubblici impone una seconda distinzione: fra **servizi a rilevanza economica** e **servizi privi di tale rilevanza**. Da essa dipendono le modalità e le procedure concrete di affidamento.

3.1 Il nuovo codice dei contratti pubblici

D.Lgs. 50/2016 (in vigore da aprile 2016): abroga il D.Lgs. 163/2006 e ne rovescia l'impostazione. Il vecchio testo era di fatto un codice dei soli appalti, perché escludeva le concessioni di servizi; il nuovo le include.

Art. 1: “il presente codice disciplina i contratti di appalto **e di concessione** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”.

- **conseguenza:** con l'inclusione delle concessioni di servizi fra le tipologie contrattuali disciplinate dal codice, nasce l'esigenza di verificare quale disciplina si applichi davvero all'affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici, prima espressamente esclusi.

Parte III — contratti di concessione, art. 164

- **comma 2:** alle procedure di aggiudicazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi si applicano, **per quanto compatibili**, le disposizioni delle parti I e II del codice — principi generali, esclusioni, modalità e procedure di affidamento, pubblicazione e redazione di bandi e avvisi, requisiti generali e speciali e motivi di esclusione, criteri di aggiudicazione, comunicazioni a candidati e offerenti, requisiti di qualificazione degli operatori economici, termini di ricezione delle domande e delle offerte, modalità di esecuzione;
- **comma 3:** “i **servizi non economici di interesse generale** non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte” → è la disposizione da cui dipende tutto il seguito, perché sottrae alla disciplina delle concessioni i servizi privi di rilevanza economica.

3.2 La classificazione dei servizi pubblici

I servizi pubblici si dividono in **servizi a rilevanza economica** e **servizi privi di rilevanza economica**. La distinzione è legata:

- all'**impatto** che l'attività può avere sull'assetto della **concorrenza**;
- ai suoi caratteri di **redditività**.

Limiti della classificazione: è **solo astratta**, priva di carattere dinamico ed evolutivo, e non può essere considerata assoluta rispetto a una considerazione globale dell'ipotesi concreta, che va valutata:

1. dal punto di vista del **servizio** che si affida (uno stadio per competizioni nazionali e internazionali, un campo di quartiere, un bocciodromo, una piscina, un impianto di tiro con l'arco non sono la stessa cosa);
2. dal punto di vista del **soggetto destinatario** dell'affidamento, cioè dell'operatore economico — anche quando sia privo di scopo di lucro;
3. dal **metodo** con cui il servizio viene fornito.

Non è quindi corretto chiedersi se la gestione di impianti sportivi abbia *sempre* o *mai* rilevanza economica.

3.3 I criteri della rilevanza economica

3.3.1 Il punto di partenza e la sua smentita

Regola generale: i servizi pubblici come quelli sportivi sono **generalmente considerati privi di rilevanza economica**, perché si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, e perché non esiste una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori — la sola gestione non consente di trarre una notevole fonte di remunerazione.

Cons. Stato n. 5072/2006: “anche i servizi cosiddetti sociali, connotati da significativo rilievo socio-assistenziale possono risultare compatibili con la nozione di servizio di rilevanza economica se e nel momento in cui presentano, per le modalità di esplicazione, una rilevante componente economica, tesa ad assicurare non solo la mera copertura delle spese sostenute ma anche un **potenziale profitto di impresa**”.

3.3.2 I due criteri

- **di rilevanza economica:** il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, **quantomeno in potenza**, una redditività; la gestione consente una **remunerazione dei fattori produttivi e del capitale** ed è quindi possibile una competizione sul mercato — e ciò **ancorché** siano previste forme di intervento finanziario pubblico (il contributo di gestione e le tariffe calmierate non escludono, da soli, la rilevanza economica);
- **privo di rilevanza:** il servizio che, per sua natura o per le modalità di gestione, **non dà luogo ad alcuna competizione**, è irrilevante ai fini della concorrenza, e la cui gestione deve rispondere al solo principio di **buon andamento** e non anche al necessario equilibrio fra costi e ricavi.

(Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006.)

L'assenza di rilevanza economica **non** autorizza però l'affidamento diretto: resta necessaria una procedura ad evidenza pubblica che ponga tutti gli operatori sullo stesso piano; sono le modalità di affidamento del servizio a rilevanza economica a essere più stringenti.

3.3.3 La valutazione caso per caso

Corte dei Conti, sez. controllo Sardegna, delib. n. 9 del 18 giugno 2007: “non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica”; la valutazione va effettuata **di volta in volta**, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell'ente stesso.

- **parametri:** l'impatto del servizio sullo specifico mercato concorrenziale di riferimento e i suoi caratteri di **redditività/autosufficienza economica**, cioè la capacità di produrre profitti o quantomeno di coprire i costi con i ricavi;
- **compito dell'ente:** valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio quanto a costi, margini di copertura degli stessi e organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della tutela della concorrenza da un lato e dell'universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall'altro;

- **conseguenza pratica:** i regolamenti comunali che elencano in anticipo quali impianti abbiano rilevanza economica fotografano la situazione al momento in cui sono redatti → l'analisi va tenuta dinamica, non trattata come acquisita.

Come la rilevanza può cambiare nel tempo

- **concorrenza sopravvenuta:** una piscina comunale unico impianto natatorio nel raggio di alcune decine di chilometri ha redditività potenzialmente elevata; la costruzione di una piscina nuova e più efficiente in un comune limitrofo può privarla di quella rilevanza. Lo stesso vale per gli stadi, quando si costruisce ex novo invece di riqualificare l'esistente;
- **modalità di utilizzo:** la stessa piscina destinata ad attività corsistica intensa — molti utenti paganti in acqua — è redditizia; destinata ad attività prettamente agonistica, con un atleta per corsia, diventa priva di rilevanza economica.

3.3.4 Ciò che non rileva: la natura dell'affidatario

È **irrilevante**, ai fini della connotazione dell'impianto e della conseguente modalità di affidamento, la natura del futuro soggetto affidatario — associazione o società sportiva dilettantistica oppure ente commerciale a tutti gli effetti.

- non è il destino dell'utile — **reinvestito** nell'attività per le finalità sociali oppure **ridistribuito** fra i soci — a determinare la potenziale redditività di un servizio pubblico, “anche se ciò ha spesso tratto in inganno”;
- l'equivoco ricorrente è ritenere che l'affidamento a un soggetto senza scopo di lucro escluda in partenza la rilevanza economica: il divieto di distribuire gli utili riguarda l'affidatario, non la natura del servizio.

3.3.5 Le variabili del settore sportivo

Nel settore sportivo è impossibile operare distinzioni precise per tipologia di impianto, perché troppe sono le variabili che incidono:

- **grandezza:** le dimensioni dell'impianto;
- **bacino d'utenza:** non coincide con la popolazione del comune, perché l'utenza si sposta più facilmente dall'hinterland verso il capoluogo che nella direzione opposta → a parità di bacino potenziale, lo stesso impianto collocato in un piccolo comune vale meno nel piano economico;
- **modalità di gestione.**

Studio caso per caso: la possibile redditività va determinata analizzando tutti i fattori capaci di indicarne la potenziale produttività — tipologie di attività praticate, costi del personale, tariffe praticabili, presenza di spazi per il pubblico (e quindi possibilità di spettacolo sportivo o di intrattenimento) e di spazi per la cartellonistica pubblicitaria.

3.3.6 La sintesi

- **impianti senza rilevanza economica:** la gestione **va assistita dall'ente pubblico**, perché non è in grado di sostenersi da sola;
- **impianti con rilevanza economica:** la gestione è in grado di **sostenersi e di produrre reddito**.

TAR Marche sez. I n. 73/2013: il servizio di gestione di impianti sportivi pubblici (nella specie una piscina comunale) che produce utili economici anche rilevanti riveste natura di servizio pubblico **a rilevanza economica**.

- non basta a escluderla il fatto che le **tariffe** debbano essere concordate con il Comune, né l'esistenza di altri vincoli a carico dell'aggiudicatario: rispondono alla finalità ultima del servizio, cioè consentire a società sportive e singoli utenti di utilizzare l'impianto;
- la sottoposizione delle tariffe all'approvazione dell'autorità concedente è del resto “un fenomeno del tutto comune in materia di concessioni di beni e servizi pubblici”.

3.4 La disciplina degli impianti privi di rilevanza economica

Quale disciplina applicare quando l'impianto è privo di rilevanza economica, cioè quando si tratta di un “**servizio non economico di interesse generale**” escluso dalla parte III del codice ex art. 164 comma 3? Le ipotesi sul tavolo sono **due**:

1. si applica la disciplina prevista per gli **appalti di servizi**;
2. si applicano **unicamente** i principi comuni della sola parte I del codice e la parte IV relativa al PPP — fra le cui forme è inserita la concessione di servizi — e non anche le ulteriori previsioni della parte III, che disciplina nello specifico i contratti di concessione.

3.4.1 Prima ipotesi: la delibera ANAC 1300/2016

Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, resa su quesito in materia di affidamento di servizi pubblici privi di rilevanza economica, ribalta la prassi fino ad allora consolidata.

1. secondo il **vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)** — Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008 — il codice CPV **92610000-0** è riferito ai “servizi di gestione di impianti sportivi”;
2. tale CPV è ricompreso nell'**Allegato IX** del D.Lgs. 50/2016 (servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144), nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”;
3. si tratterebbe quindi di un **appalto di servizi**, perché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto quale servizio reso per conto dell'amministrazione e **in assenza di rischio operativo** (art. 3 del codice);
4. ne discende che la gestione degli impianti privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni, va ricondotta agli “appalti di servizi” e aggiudicata secondo le previsioni dettate per gli **appalti di servizi sociali** (Titolo VI, sez. IV), ferma la disciplina dell'art. 36 per gli affidamenti sotto le soglie dell'art. 35;
5. **corollario:** dovrebbe ritenersi **superata e non più applicabile** la previsione dell'art. 90 comma 25 L. 289/2002 — l'affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche — perché dettata in un differente contesto normativo.

Obiezioni

- il ragionamento presuppone che il servizio privo di rilevanza economica sia **privo di rischio operativo**, mentre il rischio di perdita gestionale resta in capo al gestore: non esistono più, da tempo, convenzioni che prevedano la copertura del disavanzo da parte dell'Amministrazione;
- ne deriverebbe il **paradosso** di regole più restrittive per l'affidamento dei servizi privi di rilevanza economica — soggetti in tutto alle norme sull'appalto — che per le concessioni a rilevanza economica;

- qualificare l'affidamento come appalto implicherebbe inoltre porre il **rischio economico interamente in capo alla PA**, ipotesi non rispondente alla realtà, dato che gli impianti sono sempre più affidati alla gestione esclusiva del privato.

L'esito: la norma non è abrogata, ma va letta restrittivamente

L'art. 90 comma 25 continua a reggere le leggi regionali sull'affidamento (cap. 4). Il criterio di preferenzialità si porrebbe in violazione dei principi comunitari e delle nuove norme interne in materia di contrattualistica pubblica **solo laddove si traducesse in un semplicistico affidamento diretto** senza alcuna forma di **pubblicità preventiva**, che resta dunque necessaria in ogni caso — **anche** quando l'impianto sia privo di rilevanza economica, dove l'affidamento non può che avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato.

3.4.2 Seconda ipotesi: gli artt. 4 e 30 del codice

È la lettura considerata l'unica praticabile fino a tutto il 2016. Poiché l'art. 164 comma 3 esclude i servizi non economici di interesse generale dalla parte III, essi sono contratti **esclusi in parte** dall'ambito di applicazione del codice, e ricadono quindi nell'art. 4.

Art. 4 — principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi: l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice avviene nel rispetto dei principi di:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| • economicità; | • proporzionalità; |
| • efficacia; | • pubblicità; |
| • imparzialità; | • tutela dell'ambiente; |
| • parità di trattamento; | • efficienza energetica. |
| • trasparenza; | |

Gli ultimi due sono l'aggiunta rispetto alla formulazione dell'art. 30 del vecchio codice.

Art. 30 — principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni: l'affidamento e l'esecuzione garantiscono la **qualità delle prestazioni** e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le stazioni appaltanti rispettano inoltre i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, oltre alla pubblicità.

- **novità rilevante:** il principio di **economicità può essere subordinato** — nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice — a criteri, previsti nel bando, ispirati a **esigenze sociali**, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- è la disposizione che consente di non affidare il servizio secondo criteri puramente economici proprio là dove le esigenze sociali connotano l'offerta sportiva e la gestione di un impianto pubblico.

4 Le leggi regionali in materia di impianti sportiva sportiva

4.1 Il rinvio alla legge regionale

Art. 90 comma 25 L. 289/2002: quando l'ente pubblico territoriale — nella maggior parte dei casi il **Comune** proprietario dell'impianto — non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di **convenzioni** che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari; le **Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.**

- è una **norma quadro** proprio perché rinvia a una normativa regionale di disciplina delle modalità di affidamento: la linea guida statale è la preferenzialità, la sua declinazione concreta spetta alle Regioni;
- introduce il principio del **convenzionamento**: la convenzione è un atto *iure privatorum*, una scrittura privata, che stabilisce i criteri d'uso dell'impianto;
- i criteri generali e obiettivi per l'individuazione degli affidatari vanno **predeterminati**, a monte della procedura.

Le tredici leggi regionali emanate

- | | |
|---|---|
| 1. L.R. Valle d'Aosta 4 agosto 2006, n. 18; | 8. L.R. Marche 2 aprile 2012, n. 5; |
| 2. L.R. Puglia 4 dicembre 2006, n. 33; | 9. L.R. Abruzzo 19 giugno 2012, n. 27; |
| 3. L.R. Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27; | 10. L.R. Campania 25 novembre 2013, n. 18; |
| 4. L.R. Umbria 12 marzo 2007, n. 5; | 11. L.R. Toscana 6 marzo 2015, n. 21; |
| 5. L.R. Liguria 7 ottobre 2009, n. 40; | 12. L.R. Veneto 15 maggio 2015, n. 8; |
| 6. L.R. Calabria 22 novembre 2010, n. 28; | 13. L.R. Emilia-Romagna 31 maggio 2017, n. 8. |
| 7. L.R. Molise 9 settembre 2011, n. 18; | |

4.2 La Valle d'Aosta: L.R. 18/2006, art. 10

Regione a statuto speciale, la prima a legiferare: la legge è percorsa da passaggi che tendono a **privilegiare le società del territorio.**

I criteri di affidamento (comma 2)

Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) **apertura dell'impianto a tutti i cittadini e imparzialità** nel permetterne l'utilizzo, nel rispetto della **specificità di ogni impianto** e compatibilmente con l'attività dei soggetti affidatari;
- b) **avviso pubblico** come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) **scelta dell'affidatario** che tenga conto di esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale di istruttori e allenatori impiegati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, disabili e anziani;

- d) **selezione** da effettuare valutando sia i profili gestionali, tecnici e sociali dell'offerta, sia la sua convenienza economica, sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del **canone minimo** che intende percepire e dell'eventuale **contributo massimo** che intende concedere a sostegno della gestione;
- e) **compatibilità** delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso sportivo;
- f) determinazione della **durata massima** dell'affidamento in gestione.

Alcune precisazioni sui criteri:

- l'apertura a tutti i cittadini riprende l'**art. 90 comma 24** L. 289/2002: gli impianti sportivi pubblici vanno messi e mantenuti a disposizione di un'utenza pubblica;
- la **specificità dell'impianto** restringe di fatto la platea dei potenziali affidatari alle società che praticano quella disciplina: vale per gli impianti non polisportivi, come gli impianti per gli sport del ghiaccio, un impianto natatorio o una pista di atletica;
- giovani, disabili e anziani sono trattati come **categorie privilegiate** dalla norma;
- l'affidabilità economica fa emergere il profilo della **sostenibilità economico-finanziaria** della gestione;
- **canone** e **contributo** sono le due grandezze speculari del rapporto: il canone minimo è corrisposto dal soggetto affidatario all'ente, il contributo massimo è quanto l'amministrazione può elargire per garantire l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione.

La convenzione (comma 3)

Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto, che stabilisce in particolare i **criteri d'uso** dell'impianto e i criteri **anche economici** della gestione.

La deroga per gli impianti destinati a specifiche discipline (comma 4)

In deroga al comma 2 — e quindi all'avviso pubblico — gli enti locali, **sentito il CONI**, hanno **facoltà** (non obbligo) di affidare gli impianti sportivi **privi di rilevanza economica** e **destinati a specifiche discipline**, stipulando apposita convenzione:

- con la **federazione sportiva nazionale corrispondente**;
- ovvero con una **società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata**, da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia **garante** degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale;

resta fermo in ogni caso il comma 2 lettera a), cioè l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini.

L'esempio classico è lo **stadio del ghiaccio**; non lo è il campo da calcio, sulle cui misure sono spesso praticabili anche altre discipline, il che renderebbe difficoltoso l'affidamento a una singola federazione. È previsione da riconsiderare alla luce dell'evoluzione normativa successiva al 2006, della prassi amministrativa, delle delibere ANAC e della giurisprudenza.

4.3 L'affidamento diretto alle Federazioni sportive nazionali

Il meccanismo introdotto dalla Valle d'Aosta è stato poi utilizzato anche altrove, in altri contesti, come **escamotage** per evitare la gara. I limiti di ammissibilità:

- è ammissibile **solo** se l'impianto **non è idoneo** alla pratica di discipline regolamentate da altre FSN — cioè non è omologabile per altre attività agonistiche — e **è privo di rilevanza economica**;

- consente di evitare il ricorso alla **gara informale** mediante invito di minimo **5 concorrenti** (previsione del vecchio codice dei contratti), ma non può in alcun modo derogare ai **principi comunitari di trasparenza e non discriminazione**;
- va valutata la presenza, sul territorio di riferimento, di **enti di promozione sportiva** (EPS) o loro affiliati che praticino la disciplina cui l'impianto è destinato e che non siano affiliati alla federazione di riferimento: la questione non si esaurisce quindi guardando alla sola FSN;
- ove la FSN **non gestisse direttamente** l'impianto, sarebbe parimenti tenuta a esperire una **procedura ad evidenza pubblica** per l'affidamento in gestione.

Il fondamento: art. 23 comma 1 Statuto CONI

“...hanno **valenza pubblicistica** le attività delle Federazioni sportive nazionali relative ... all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici...”

- le FSN sono **associazioni di diritto privato**, ma a questi fini vanno considerate **organismi di diritto pubblico**: lo Statuto CONI elenca una serie di attività delegate dal CONI, ente pubblico, alle federazioni, che hanno appunto valenza pubblicistica;
- in questi ambiti le federazioni devono ottemperare ai criteri e ai principi di trasparenza della **L. 241/1990** sul procedimento amministrativo e agli adempimenti conseguenti;
- ne segue che la normativa valdostana è **imprudente**, o quantomeno audace, nel prevedere l'affidamento diretto a federazioni o ad affiliati da esse indicati senza chiarire che anche le federazioni sono tenute a una **procedura comparativa** fra i propri affiliati, o quantomeno fra quelli del territorio di riferimento.

4.4 Dalla Puglia all'Emilia-Romagna

4.4.1 Puglia — L.R. 33/2006, art. 18 (mod. L.R. 32/2012)

Attua l'art. 90 comma 25 disciplinando le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

- **ambito di applicazione**: gli impianti di proprietà di enti pubblici territoriali **non gestiti direttamente** dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive **di qualsiasi livello**, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico;
- ribadisce il principio del comma 24: l'uso degli impianti è **aperto e accessibile a tutte le cittadine e a tutti i cittadini**;
- i soggetti affidatari sono individuati con **procedure di evidenza pubblica** fra coloro che presentano idonei requisiti e garantiscono le finalità dell'art. 18;
- la gestione è affidata **in via preferenziale, favorendone l'aggregazione**, a FSN, discipline sportive associate (DSA), EPS riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche con i requisiti dell'art. 90 L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi — quindi iscritte al registro CONI;
- l'uso dell'impianto va garantito **anche ai soggetti non affidatari**, purché in possesso degli stessi requisiti: vale cioè il principio dell'utilizzo plurimo.

La locuzione “in via preferenziale” è riportata *sic et simpliciter* dalla norma nazionale, **senza declinare** il concetto di preferenzialità: sotto il profilo dell'affidamento la legge pugliese non offre spunti di novità.

4.4.2 Lombardia — L.R. 27/2006

È la legge che più di ogni altra **differenzia la procedura di selezione** a seconda che si tratti di impianto con o senza rilevanza economica. Vi ha inciso il dibattito in corso all'epoca dell'approvazione sull'affidamento dei servizi privi di rilevanza economica, poi sfociato in modifiche normative e in un quesito referendario.

- **impianti con rilevanza economica** — cioè la cui gestione è capace di produrre reddito — che per dimensioni e altre caratteristiche richiedono una **gestione di tipo imprenditoriale**: le società e associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare di avere i **requisiti imprenditoriali e tecnici necessari**. La qualifica di ASD o SSD non è di per sé sufficiente: la preferenzialità resta, ma condizionata alla capacità di una gestione manageriale, spesso richiesta da impianti a tecnologia complessa;
- **impianti senza rilevanza economica: affidamento diretto** ammesso anche **agli utilizzatori** degli impianti stessi.

4.4.3 Umbria — L.R. 5/2007, art. 4

Affidamento diretto per gli impianti privi di rilevanza economica (comma 4)

Ammesso nei casi seguenti:

- a) quando sul territorio di riferimento è presente un **solo soggetto** che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto — una gara sarebbe inutile;
- b) quando il servizio è affidato direttamente a una **società a capitale interamente o a maggioranza pubblica**, costituita nelle forme dell'art. 90 comma 17 lettera c) L. 289/2002. Se il capitale è solo a maggioranza pubblica, e non interamente pubblico, si applicano le norme sulle **società in house** e occorre comunque una procedura selettiva per individuare il socio privato;
- c) quando i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un **unico soggetto sportivo**: raggruppamento temporaneo, polisportiva di secondo livello o altra forma di aggregazione fra tutti i soggetti che avrebbero i requisiti per ambire alla gestione. Anche qui la gara può essere bypassata, ma l'affidamento diretto dev'essere preceduto da forme di pubblicità sulla volontà dell'amministrazione di aggiudicare l'impianto.

Impianti con rilevanza economica (commi 5–6)

- l'affidamento avviene con **procedura ad evidenza pubblica**, aperta anche ai soggetti dell'art. 90 comma 17 L. 289/2002 e ai loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri del comma 2 lettere a), b), c) e dei vincoli statali e comunitari;
- sono ammesse a partecipare anche **società di capitali**, pure in aggregazione con i soggetti dell'art. 90 comma 17 lettere a) e b): soggetti *profit* che concorrono insieme ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

4.4.4 Liguria — L.R. 40/2009, art. 19

Il tratto caratterizzante è un'**esclusione** dall'applicazione del capo:

- a) gli impianti situati in **comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, a eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;
- b) gli impianti facenti parte del **patrimonio regionale**, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.

Resta garantito a tutti i cittadini l'uso degli impianti sportivi pubblici (art. 2).

La prima esclusione è tecnicamente e giuridicamente discutibile, pur comprendendone la *ratio*: un impianto a rilevanza economica può ben trovarsi nel territorio di un comune sotto i 5.000 abitanti pur ricadendo in un'area metropolitana, e l'eccezione limitata a piscine e palazzi dello sport non è sufficiente a coprire l'ipotesi.

4.4.5 Sardegna — L.R. 17/1999, art. 21

Regione autonoma, con una previsione di legge e un regolamento attuativo. È legge **anteriore** all'art. 90 L. 289/2002, in vigore dal 2003, e la sua datazione traspare dalla terminologia usata.

Regolamento di gestione degli impianti

- gli enti e le associazioni beneficiarie delle **provvidenze** previste dalla legge — i contributi — sono tenuti ad adottare un **regolamento di gestione** degli impianti, formulato sulla base del **regolamento tipo** predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport e approvato dalla Giunta regionale;
- nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso va garantito ai **sodalizi sportivi** e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla **popolazione scolastica** che non disponga di adeguate strutture;
- le stesse disposizioni si applicano alle opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.

Criteri per l'assegnazione (regolamento ex art. 21)

La **priorità** nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata, tenendo conto in via prioritaria di:

- | | |
|---|--|
| • numero degli atleti tesserati; | • risultati agonistici ottenuti; |
| • anni di attività del sodalizio; | • attività di promozione dello sport fra i giovani in età scolare. |
| • livello dei campionati cui partecipa; | |

La norma parla di **priorità** e non di preferenzialità — è anteriore all'art. 90 — ma il concetto è il medesimo. La previsione sconta però la disciplina dell'epoca e non è più adeguata agli standard del codice dei contratti pubblici né all'orientamento di derivazione comunitaria, anche in materia di concessioni demaniali: non è più possibile riconoscere un **diritto di insistenza** a chi già gestisce l'impianto o vi opera.

4.4.6 Molise — L.R. 18/2011, art. 2

- gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti, anche mediante convenzione fra gli enti stessi, ne affidano **in via preferenziale** la gestione a società sportive, ASD, EPS, DSA e FSN, anche in forma associata;
- l'affidamento avviene **prioritariamente** a vantaggio dei soggetti che praticano la disciplina cui l'impianto è destinato e che operano nel territorio dell'ente affidatario, secondo il **criterio territoriale**: comune, provincia, regione;
- **elemento di novità**: l'affidamento a **soggetti diversi** avviene solo in caso di **esito infruttuoso** delle procedure di selezione dell'art. 3, e comunque nel rispetto dei relativi principi — prima una procedura fra i soggetti sportivi indicati da legge statale e regionale, poi, solo se andata deserta, l'apertura ad altri;

- per gli **impianti con rilevanza economica** che richiedono una gestione di tipo imprenditoriale l'affidamento avviene con **procedura di evidenza pubblica** e i soggetti sportivi devono dimostrare di possedere i **requisiti economici e tecnici** necessari — come già previsto dalla legge lombarda.

4.4.7 Marche — L.R. 5/2012, art. 19

- i soggetti affidatari sono individuati fra coloro che presentano idonei requisiti, con **procedure di evidenza pubblica** nel rispetto della normativa vigente;
- la gestione è affidata **in via preferenziale** a SSD e ASD, EPS, DSA e FSN;
- gli enti territoriali stipulano con gli affidatari **convenzioni** che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti;
- l'uso dell'impianto è garantito **anche alle società e associazioni non affidatarie**.

4.4.8 Campania — L.R. 18/2013, art. 20

Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente, nel rispetto del principio di **imparzialità della scelta**, affidano la gestione al CONI, al **CIP** — Comitato italiano paralimpico, ente pubblico esplicitamente menzionato accanto al CONI — alle FSN, agli EPS o alle DSA, alle ASD iscritte alla sezione A prevista dall'art. 11 comma 2, che garantiscono:

- a) l'**apertura dell'impianto** a tutti i soggetti e, per le piscine, adeguati spazi per il **nuoto libero**;
- b) esperienza nel settore, radicamento nel territorio del bacino di utenza, affidabilità economica, qualificazione professionale di istruttori e operatori;
- c) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani;
- d) compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico con il normale uso sportivo;
- e) lo svolgimento dell'**attività agonistica**;
- f) la destinazione di **investimenti** alla migliore fruizione dell'impianto.

Procedura (commi 3–4)

- **avviso pubblico** come modalità di pubblicità della selezione, trasmesso alla competente struttura regionale che ne cura la pubblicazione nel **Bollettino Ufficiale della Regione**;
- la selezione avviene in ragione della diversa tipologia di impianto, nel rispetto dei criteri di **proporzionalità, non discriminazione e trasparenza**, all'esito della valutazione dei **progetti** presentati, che consentono di apprezzare i profili economici e tecnici della gestione;
- si tiene conto anche del **canone minimo** che l'ente intende percepire e del **contributo massimo** che intende concedere a sostegno della gestione.

Affidamento diretto nei comuni sotto i 5.000 abitanti

In deroga, il servizio può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:

- a) quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività **esclusivamente amatoriali e ricreative** — non omologabili per l'attività agonistica — riferibili al territorio dove sono ubicati;
- b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un **solo soggetto** che promuove la disciplina praticabile presso l'impianto;

- c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio costituiscono un **unico soggetto sportivo**, anche in forma associativa o consortile.

4.4.9 Toscana — L.R. 21/2015, art. 14

- gli enti locali che non intendono gestire direttamente affidano la gestione **in via preferenziale** a ASD e SSD, EPS, DSA e FSN, secondo **procedure ad evidenza pubblica**;
- l'affidamento a **soggetti diversi** avviene solo in caso di **esito infruttuoso** delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei relativi principi — come già nel Molise.

4.4.10 Veneto — L.R. 8/2015, artt. 25–26

- affidamento **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche **senza fini di lucro**, FSN, DSA ed EPS, nonché a **consorzi e associazioni** fra i predetti soggetti;
- affidamento a soggetti diversi, in possesso di idonei requisiti, **esclusivamente** in caso di esito infruttuoso delle modalità dell'art. 26;
- l'individuazione avviene con **procedure ad evidenza pubblica** nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
- **affidamento in via diretta** ammesso quando ricorre almeno uno dei presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un **solo soggetto** che promuova la disciplina praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un **unico soggetto sportivo**.

4.4.11 Emilia-Romagna — L.R. 8/2017

È l'ultima legge regionale approvata in materia. Gli enti locali disciplinano condizioni e modalità di affidamento in gestione degli impianti, con particolare riferimento a quelli aventi **minore rilevanza economica** — formula che si colloca fra le due categorie consuete e allude agli impianti a redditività limitata — sulla base dei principi seguenti:

- a) **compatibilità** fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio;
- b) **valorizzazione delle potenzialità** degli impianti, con un rapporto equilibrato — ove compatibile con le caratteristiche degli impianti — fra normale uso sportivo, utilizzazione da parte del pubblico, attività di promozione della pratica sportiva e attività ricreative e sociali;
- c) valutazione dei requisiti di **qualificazione e affidabilità economica**, nonché delle competenze e capacità maturate in precedenti esperienze di gestione;
- d) valutazione dell'offerta sulla base del **miglior rapporto fra qualità e prezzo** — l'offerta economicamente più vantaggiosa — secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'**equilibrio economico** della gestione.

La Regione individua inoltre **linee guida** contenenti migliori pratiche **non vincolanti**, ai fini della loro promozione sul territorio, e le correlate definizioni applicative.

4.5 La competenza all'affidamento: Giunta o Consiglio comunale?

TAR Calabria 1 luglio 2010, n. 141: risolve il dubbio muovendo dall'**art. 42 TUEL**, che definisce il **Consiglio comunale** "l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" dell'ente, attribuendogli "la competenza in materia di appalti (...) lasciando il concreto affidamento dell'appalto alla competenza della **Giunta**, in quanto attività meramente esecutiva o di ordinaria amministrazione".

4.6 Sintesi della disciplina applicabile

I criteri ricorrenti nelle leggi regionali

- **preferenzialità declinata come priorità procedurale:** Molise, Toscana e Veneto riservano una prima procedura ai soli soggetti sportivi e aprono ad altri solo in caso di esito infruttuoso. È il tentativo più esplicito di dare contenuto operativo alla locuzione dell'art. 90 comma 25, ed è già stato oggetto di **censura da parte della Commissione europea** per violazione delle norme e dei principi sulla concorrenza;
- **preferenzialità non declinata:** la Puglia riprende la formula statale senza precisarla;
- **differenziazione per rilevanza economica:** Lombardia, Umbria e Molise distinguono la procedura a seconda che l'impianto abbia o meno rilevanza economica, richiedendo requisiti imprenditoriali e tecnici quando la gestione dev'essere di tipo imprenditoriale;
- **presupposti tipici dell'affidamento diretto:** unico soggetto che promuove la disciplina sul territorio; aggregazione di tutti i soggetti sportivi in un unico soggetto; società a capitale pubblico (Umbria); impianto privo di rilevanza economica destinato a specifica disciplina (Valle d'Aosta);
- **canone minimo e contributo massimo** come parametri della valutazione economica dell'offerta (Valle d'Aosta, Campania);
- **comuni sotto i 5.000 abitanti:** la Liguria li **esclude** dall'applicazione della disciplina, la Campania consente loro l'**affidamento diretto** a condizioni determinate.

La conclusione

Il criterio di preferenzialità dettato dall'art. 90 comma 25 L. 289/2002 si porrebbe in evidente violazione:

- dei **principi comunitari** di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e soprattutto trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- delle **nuove norme interne** in materia di contrattualistica pubblica;

ma solo **laddove si traducesse in un semplicistico affidamento diretto** senza ricorrere ad alcuna forma di **pubblicità preventiva**, che è dunque necessaria in ogni caso.

Anche quando l'impianto **non** avesse rilevanza economica, l'affidamento non potrebbe che avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal **Trattato** — art. 30 D.Lgs. 163/2006, per come poi riportato anche nel nuovo codice dei contratti pubblici.

5 Le forme di partenariato pubblico privato

5.1 La nozione di partenariato pubblico privato

Partenariato pubblico privato (PPP): particolari forme di partecipazione dell'**iniziativa imprenditoriale privata** finalizzate a progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di **opere pubbliche o di pubblica utilità**, ovvero alla fornitura di beni o all'erogazione di servizi. È l'**unione degli interessi della collettività** con quelli dell'iniziativa imprenditoriale privata.

Perché se ne ricorre

La gestione di un impianto sportivo rientra fra i **servizi pubblici**, in particolare fra i servizi sociali. Il PPP entra in gioco quando l'ente proprietario — oltre a non voler gestire direttamente l'impianto — non ha o non intende impegnare risorse pubbliche per costruire nuovi impianti o anche solo per riqualificare, riconvertire, ammodernare o mettere in sicurezza quelli esistenti:

- pesano i **vincoli di finanza pubblica**: prima il patto di stabilità, oggi il pareggio di bilancio;
- il capitale privato (società sportive, investitori, banche, imprese di costruzioni) si unisce in progetti che devono comunque restare volti all'**interesse pubblico**.

La definizione contrattuale — art. 3 D.Lgs. 50/2016

“Il **contratto a titolo oneroso** stipulato per iscritto con il quale una o più **stazioni appaltanti** conferiscono a uno o più **operatori economici** per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella **realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa** di un'opera in cambio della sua **disponibilità**, o del suo **sfruttamento economico**, o della **fornitura di un servizio** connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con **assunzione di rischio** secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.”

Gli elementi della definizione:

- **titolo oneroso**: non esistono forme di partenariato a titolo gratuito. È sempre un *do ut des* — si realizza l'opera pubblica avendo come contropartita la possibilità di gestirla e sfruttarla economicamente per il periodo di concessione;
- **le parti**: la stazione appaltante è la parte pubblica, nella maggior parte dei casi il Comune committente; l'operatore economico è il soggetto affidatario e gestore;
- **la durata**: commisurata all'ammortamento dell'investimento o alle modalità di finanziamento fissate;
- **l'assunzione del rischio** da parte dell'operatore, secondo le modalità del contratto.

Realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa in cambio della disponibilità o dello sfruttamento economico dell'opera si adattano bene alla gestione di un impianto sportivo e di uno stadio di calcio.

5.2 L'allocazione dei rischi

La qualificazione dei contratti di PPP — art. 180 D.Lgs. 50/2016

Il nuovo codice, per meglio qualificare i contratti di PPP, chiarisce che i **ricavi di gestione** devono derivare:

- dal **canone** riconosciuto dall'ente concedente;
- e/o da **ulteriori introiti** derivanti dalla gestione del servizio;

purché permanga in capo all'operatore privato, oltre al **rischio di costruzione**, anche il **rischio di disponibilità** o — nei casi di attività redditizia verso l'esterno — il **rischio della domanda**.

Le quattro fattispecie di rischio — art. 3 D.Lgs. 50/2016

- **rischio operativo**: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico nei casi dell'art. 180. Si considera assunto quando, in **condizioni operative normali** — cioè in assenza di eventi non prevedibili — **non è garantito il recupero degli investimenti** effettuati o dei costi sostenuti per la gestione. La parte di rischio trasferita deve comportare una **reale esposizione alle fluttuazioni del mercato**, tale per cui ogni potenziale perdita stimata non sia puramente nominale o trascurabile;
- **rischio di costruzione**: il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera — è ciò che in Italia ha bloccato o ritardato in modo patologico molte opere pubbliche;
- **rischio di disponibilità**: il rischio legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti;
- **rischio di domanda**: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare — la risposta dell'utenza — ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa sufficienti a remunerare l'investimento.

Il rischio operativo deve in ogni caso restare in capo all'operatore economico privato in **misura maggioritaria**.

5.3 L'equilibrio economico-finanziario e il prezzo

Equilibrio economico e finanziario (art. 3 comma 1): la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

- **convenienza economica**: capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di **redditività adeguato per il capitale investito**;
- **sostenibilità finanziaria**: capacità del progetto di generare **flussi di cassa** sufficienti a garantire il **rimborso del finanziamento**.

Il prezzo e il limite del 49%

L'equilibrio economico-finanziario è il **presupposto per la corretta allocazione dei rischi**. A tal fine, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un **prezzo** — più semplicemente, un contributo — consistente in:

- un **contributo pubblico**;
- ovvero la **cessione di beni immobili** che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico (è il caso, molto discusso, delle caserme in disuso).

In ogni caso il riconoscimento del prezzo, **sommato** al valore di eventuali **garanzie pubbliche** o di ulteriori **meccanismi di finanziamento** a carico della pubblica amministrazione, non può superare il **49% del costo dell'investimento complessivo**, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

- la precedente formulazione della norma fissava il limite al **30%**: ha operato dal momento di entrata in vigore del codice, aprile 2016, fino ad **aprile 2017**;

- in quell'anno gli interventi in forma di PPP sono **calati fortemente**. Un impianto sportivo fatica a remunerare l'investimento — con una partita ogni due settimane, per dirla brutalmente — e la sua rilevanza economica, e con essa la capacità di generare flussi di cassa, può essere limitata: un contributo pubblico è pressoché necessario;
- l'innalzamento al 49% sfrutta l'estensione più ampia consentita dalla **direttiva comunitaria**, che richiede il permanere del rischio in misura maggioritaria a carico del privato: il limite sottintende cioè che almeno il **51% del rischio**, anche economico, resti in capo al soggetto privato.

5.4 La contabilizzazione off balance e il ricorso al mutuo

Le decisioni Eurostat

Agli enti locali che investono in un contratto di partenariato ex art. 180 sono pacificamente applicabili le **decisioni Eurostat**, che consentono di contabilizzare **off balance** — fuori bilancio — gli *asset* oggetto dell'operazione, a condizione che vi sia una **chiara allocazione del rischio di disponibilità** in capo alla controparte privata.

- le risorse impiegate non gravano quindi sul bilancio dell'ente né sui suoi equilibri;
- la PA può così realizzare **opere strategiche** senza sottostare ai pesanti vincoli imposti dai principi contabili in tema di investimenti — vincoli che, nella suddivisione del bilancio pubblico fra **spese correnti** e **spese di investimento**, bloccano spesso l'investimento diretto della parte pubblica.

Il mutuo per finanziare il prezzo

Gli enti locali possono assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione anche mediante un "prezzo". Per reperire le risorse necessarie ai **trasferimenti in conto capitale** a favore dei concessionari di lavori pubblici (artt. 165 e 180 D.Lgs. 50/2016) a titolo di prezzo si può **contrarre un mutuo** — con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'Istituto per il Credito Sportivo e non solo — poiché tali trasferimenti costituiscono investimenti per i quali agli enti locali è consentito indebitarsi.

Art. 3 comma 18 L. 350/2003 (finanziaria per il 2004, antenata dell'odierna legge di bilancio): ai fini dell'art. 119 sesto comma della Costituzione, costituiscono investimenti per i quali gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento, fra gli altri, alla lettera h):

i **contributi agli investimenti** e i **trasferimenti in conto capitale** a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la **retrocessione degli investimenti** agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.

5.5 Le questioni interpretative sul limite del 49%

Il limite introdotto dal D.Lgs. 50/2016 apre una serie di dubbi, non ancora risolti, su che cosa entri nei due termini del rapporto.

Che cosa entra nel costo dell'investimento

- gli **interessi del mutuo** vanno computati al **valore nominale** o **attualizzati**? Su un intervento di 20, 25 o 30 anni la differenza non è di poco conto. E se vanno attualizzati, con quale tasso — quello usato per determinare il valore degli aiuti di Stato *de minimis*?
- se per la determinazione del prezzo si considerano i contributi in conto gestione, vanno correlativamente inserite nel costo dell'investimento anche le **spese di gestione**? Si pensi alle concessioni e ai contratti di partenariato che prevedono espressamente la gestione dell'impianto. Quali, entro quali limiti, attualizzate a quale tasso?

Che cosa entra nel prezzo

- i **contributi pluriennali per la gestione** — quelli che la PA conferisce ogni anno per garantire l'equilibrio economico-finanziario, per esempio quando ha imposto al gestore **tariffe calmierate**. Vanno computati solo se non sottoposti nell'erogazione a condizioni (disponibilità di bilancio del Comune, calcolo come differenza fra costi sostenuti e ricavi della gestione)? Le condizioni sempre previste per la **revoca della concessione** — non specificamente riferite ai contributi — bastano a escluderli dal computo? E se vanno considerati, vanno attualizzati e a quale tasso?
- i contributi esclusi dal computo vanno **reinseriti** se formano oggetto di **cessione all'ICS** con funzione di garanzia e di pagamento del mutuo?
- la **concessione di diritti reali** — tipicamente il **diritto di superficie** concesso al mutuatario per realizzare l'opera e per poter concedere ipoteca alla banca — va computata nel prezzo, e come? Come **differenziale** fra il costo di mercato per la fruizione del diritto e quello effettivamente corrisposto (area che vale 10 e ceduta a 7: contributo pubblico pari a 3)? Il beneficio va attualizzato e a quale tasso? La questione ha peso perché in passato il diritto di superficie veniva concesso a **cifre simboliche**, anche di un euro, mentre l'esistenza di un tetto al contributo pubblico impone di valorizzare adeguatamente anche la cessione dell'area su cui edificare;
- fra le **garanzie pubbliche** va considerata la **fideiussione comunale** — oggi sempre più rara, sostituita dalla concessione di diritti reali? E al valore nominale o come **Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**, eventualmente calcolato col metodo fissato per gli aiuti di Stato?

L'intreccio con gli aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato sono in linea di massima **vietati** a livello europeo e costantemente attenzionati dalla Commissione. Il problema dei contributi pluriennali del Comune al concessionario rileva anche su questo piano: si devono considerare solo quando sono **trasparenti**, cioè calcolabili con precisione *ex ante*, al momento della stipula. Ci si chiede allora se occorra tener conto della possibile revoca della concessione per inadempimenti contrattuali — escludendoli dal computo — oppure se vadano esclusi solo in presenza di clausole specificamente riferite ai contributi che ne rendano incerta l'erogazione.

La ricostruzione proposta

Prevale una lettura **non restrittiva**, coerente con la direttiva europea:

- nel **costo dell'investimento** su cui calcolare il 49% vanno inseriti il costo totale delle opere, il costo del finanziamento comprensivo di **interessi attualizzati** e gli **oneri di gestione complessivi**;
- nel **prezzo**, unito agli altri “aiuti pubblici”, vanno sommati:
 - trasferimenti in conto capitale e immobili;
 - valore dei **diritti reali di godimento** (p. es. il diritto di superficie);
 - **contributi pluriennali** anche in conto gestione, attualizzati e anche se sottoposti a condizioni;
 - valore della **fideiussione comunale** e di altre garanzie pubbliche, calcolato come ESL;

- valore attualizzato di altri **contributi pubblici pluriennali**, compresi quelli in conto interessi.

5.6 I fondi immobiliari

Art. 33 comma 2 D.L. 6 luglio 2011, n. 98: i comuni privi di risorse proprie da destinare al recupero, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di impianti sportivi — stadi, palazzetti dello sport — possono **apportare** detti impianti, o i diritti reali a essi relativi, a un **fondo immobiliare** costituito *ad hoc*.

- in cambio gli enti ricevono **quote del fondo**;
- il fondo trae dalla **valorizzazione degli asset immobiliari** conferiti la remunerazione dei capitali raccolti sul mercato e in esso investiti.

5.7 Le tipologie di contratti di PPP

Nella tipologia dei contratti di PPP rientrano:

- la **finanza di progetto** (*project financing*), in cui la fase progettuale è a carico del privato;
- la **concessione di costruzione e gestione**, che dal *project financing* differisce perché è la parte pubblica ad accollarsi gli **oneri di progettazione**: il capitolato e le caratteristiche strutturali dell'impianto vanno a bando con studi progettuali già approvati dall'amministrazione;
- la **concessione di servizi**, dove non vi è necessariamente una componente preponderante di lavori e la remunerazione viene dalla prevalente gestione del servizio pubblico;
- la **locazione finanziaria di opere pubbliche** (*leasing*);
- il **contratto di disponibilità**;

e **qualunque altra procedura** di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presenti le caratteristiche dei commi precedenti — formula sufficientemente ampia da comprendere anche schemi non ancora codificati.

5.8 Le procedure di affidamento

La scelta dell'operatore economico avviene con **procedure ad evidenza pubblica**, anche mediante **dialogo competitivo**.

Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia a oggetto **anche l'attività di progettazione**, le amministrazioni aggiudicatrici pongono a base di gara:

- il **progetto definitivo**;
- uno **schema di contratto** — la convenzione per la gestione dell'impianto e il regolamento d'uso;
- un **piano economico finanziario**;

che disciplinino l'**allocazione dei rischi** fra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, verificando che il rischio permanga in misura maggioritaria — almeno il 51% — a carico dell'operatore privato.